

1501234-79.2020.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: DANILO BRAIT

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... Reafirmou que as informações eram sobre tráfico contra o acusado Vinícius.

Explicou que, geralmente, nos casos de tráfico, quem é pego com a droga assume a propriedade para livrar quem não estava perto. A equipe já tinha informações sobre o envolvimento do réu Vinícius e sua companheira Grayce Kelly com o tráfico, mas não havia denúncia sobre o réu Mateus, o qual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, nº 60 - Vila São Paulo - Araçatuba/SP - CEP 16015-925

1501234-79.2020.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501234-79.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 8306/20/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS LUIS BARBOSA DE SOUZA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANILO BRAIT

Vistos.

MATEUS LUÍS BARBOSA DE SOUZA e VINÍCIUS BALDENEIRO BATISTA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29, "caput", do Código Penal, porque, segundo consta na denúncia, o réus, conluiados e previamente ajustados para a prática criminosa, no dia 24 de agosto de 2020, por volta das 17h30min., na residência situada na Rua Joana Favarin Jorge, nº 805, no Bairro Água Branca, nesta cidade e comarca, traziam consigo, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 427,43 gramas de "Benzoilmetilecgonina", substância entorpecente vulgarmente conhecida por "cocaína", e 830,77 gramas de "Cannabis Sativa L", substância vulgarmente conhecida por "maconha", drogas essas capazes de causar dependência.

Os réus foram presos em flagrante em 24/08/2020. Pela r. decisão de fls. 97/101 a prisão em flagrante de Mateus foi convertida em prisão preventiva, sendo concedida a liberdade provisória ao réu Vinicius. Mandado de prisão cumprido em 25/08/2020 (fls. 116/117). Alvará de Soltura cumprido em 25/08/2020 (fls. 118/119).

Os réus foram notificados às fls. 184/185 e apresentaram respostas á acusação às fls. 189/194 e 212/219. Não estando presente nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397, do Código de Processo Penal, a denúncia foi recebida em 05 de março de 2021, sendo deferida a gratuidade da justiça aos acusados (fls. 224/227).

Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, foi mantida a prisão preventiva do acusado Mateus (fls. 164/165, 232/233 e 281/282).

Durante a instrução processual foram ouvidas três testemunhas em comum, sendo ao final, interrogados os acusados (fls. 325/335).

Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou, em síntese, pela parcial procedência da ação penal, para o fim de absolver o réu Vinicius Baldenebro Batista por insuficiência de provas, e condenar o corréu Mateus Luís Barbosa de Souza pela prática do delito insculpido no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas, vez que comprovadas a materialidade e autoria delituosa, notadamente em razão da confissão em juízo. Na dosimetria da pena, requereu o reconhecimento da reincidência específica do acusado e dos atos de tráfico praticados durante a adolescência, refutando a incidência da atenuante da confissão espontânea, vez que o acusado confessou parcialmente os fatos.

Em alegações finais orais, a defesa do réu Vinicius Baldenebro Batista pugnou, em síntese, pela absolvição do acusado por ausência de provas.

Em alegações finais (fls. 331/333), a defesa do réu Mateus Luis Barbosa de Souza pugnou pelo reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal) e da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), bem como da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima (2/3), com fixação de regime inicial aberto ou semiaberto e substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

É o relatório.

#### FUNDAMENTO.

O pedido inicial é parcialmente procedente, impondo-se a absolvição do réu Vinicius Baldenebro Batista e a condenação do réu Mateus Luís Barbosa de Souza pelo delito de tráfico de drogas.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 08), boletim de ocorrência (fls. 17/20), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), laudo de constatação prévia de entorpecentes (fls. 23/26), laudos de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 130/144), relatório policial (fls. 149/150), bem como pela prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria, contudo, restou comprovada somente em relação ao acusado Mateus Luís Barbosa de Souza.

A testemunha comum Elias Pichirilo Júnior, policial civil, ouvido em juízo (fl. 327), em consonância com o depoimento prestado na fase policial (fl. 09), disse que recebeu informações de que os moradores do local estavam vendendo entorpecentes.

Tentou realizar uma diligência, entretanto, existem muitos "olheiros" no local. Informou que já conhecia a referida casa como ponto de venda de entorpecentes, motivo pelo qual conseguiram um mandado de busca e apreensão. Contou que foram recebidos por Grayce Kelly, a qual informou que só estariam na residência seu pai e os filhos. Entretanto, foi percebida uma movimentação no fundo da casa, que chamou a atenção dos policiais. Relatou que viu alguns indivíduos no fundo da residência, inclusive um que vestia camiseta vermelha e saiu com uma sacola preta, tentando escalar o muro. Foi então que avisou o policial Alexandre, que estava próximo à residência vizinha, sobre a fuga. Adentrou o quintal da casa e abordou o réu Vinícius, juntamente com mais três pessoas. O policial Alexandre retornou com o acusado Mateus já detido e com a sacola, que continha em seu interior 522 pinos de cocaína, 117 porções de maconha, 22 tabletes de maconha e uma balança de precisão digital. Contou que, primeiramente, o acusado Mateus ficou em silêncio, mas depois confirmou que estaria vendendo entorpecentes. Entretanto, não disse de quem seria a droga. Em relação ao acusado Vinícius, este afirmou que estaria ali somente conversando. O depoente relata que, levando em conta as denúncias, ambos os acusados foram conduzidos ao plantão, certo que Grayce Kelly foi conduzida na condição de investigada. Informou que as denúncias foram feitas por moradores daquele local, mas que ao chegarem à casa, já sabiam sobre quem eram. Relatou que Grayce Kelly e o réu Vinícius já são bem conhecidos nos meios policiais devido à traficância. Contou que o cumprimento do mandado foi feito no dia em que o receberam, salvo engano. Relatou que já conhecia o réu Mateus por abordagem de tráfico, mas as informações iniciais não eram sobre ele. Disse que no momento da abordagem nenhum dos indivíduos falou nada sobre as drogas, porém, no plantão policial, o acusado Mateus admitiu a comercialização da droga, mas não esclareceu a propriedade dela. Em relação à participação do acusado Vinícius o acusado Mateus ficou em silêncio. Não tem informações sobre o uso de drogas pelos envolvidos. Afirmou que já fez busca naquela residência, mas não foi feita nenhuma apreensão. Informou que no dia dos fatos não foi encontrado nada na residência, apenas na sacola que estava com o réu Mateus. Reafirmou que chegou uma informação anônima de que naquele local havia a venda de entorpecentes. Informou que nada foi encontrado com o réu Vinícius. Relatou que o acusado Vinícius disse que não sabia nada sobre o que foi encontrado com o réu Mateus. Não se recorda se o acusado Vinícius disse algo sobre Mateus ter ido tomar água em sua residência. Informou que os entorpecentes foram levados para o plantão policial da mesma forma em que foram encontrados. Explicou que quando foram apreendidas as drogas todas já estavam embaladas. Afirmou que a abordagem do réu Vinícius foi bem tranquila. Ademais, foi explicado para ele o teor das denúncias e foram lidos seus direitos. Nega que o acusado Vinícius tenha contado sobre problemas com uma vizinha. Nega que tenha lido os depoimentos dos acusados após a ocorrência. Explicou que quando chegou ao local dos fatos, Grayce Kelly afirmou que somente estariam na residência com ela seu pai e as crianças, entretanto, ouviu barulhos no fundo da casa e conseguiu olhar por cima do muro a movimentação de lá. Informou que o acusado Mateus, que vestia a camiseta vermelha, tentou escalar o muro com a sacola na mão.

A testemunha comum Alexandre Procópio Neves, policial civil, ouvido em juízo (fl. 326), em consonância com o depoimento prestado na fase policial (fl. 10), disse que foi recebida pela equipe denúncia sobre a prática de tráfico de entorpecentes no local dos fatos, que é de difícil acesso para policiais, tendo em vista que existem muitos "olheiros" informando a presença de viaturas no bairro. Informou que chegaram ao local e foram recebidos por Grayce Kelly, que afirmou ao policial Elias que dentro da residência só estavam seu pai e seus filhos. Porém, percebia-se uma movimentação no fundo da casa. O depoente estava tentando olhar por cima do muro a movimentação. No momento em que Grayce Kelly abriu o portão para que os policiais entrassem, o policial Elias informou que havia um indivíduo indo para o telhado com uma sacola. O depoente desceu do muro e contornou a residência, esperando que esse indivíduo descesse por ali. Afirmou que quando o indivíduo desceu foi dada a voz de prisão, mas ele não parou. Correram uns 30 metros até que o deteve. Ao conduzir o indivíduo até a residência, achou, no caminho de volta, uma sacola com drogas e uma

balança de precisão. Relatou que o acusado disse: “o corre é meu”. Questionado se tudo lhe pertencia, não respondeu. O depoente afirmou que estava no fundo da residência com o acusado Vinícius. Ressaltou que a denúncia era sobre a venda de drogas na residência por parte dos moradores, mas que o entorpecente foi encontrado com esse indivíduo que estava na casa e tentou fugir. Esse indivíduo citado é o acusado Mateus. A sacola foi jogada pelo acusado Mateus depois de fugir por cima de, aproximadamente, duas casas. Relatou que, primeiramente, o réu Mateus disse que correu por medo, negando a posse das drogas, mas depois de apresentadas as drogas encontradas, admitiu que eram suas. Não perguntou a Mateus sobre o envolvimento de Vinícius com aquelas drogas. Reafirmou que as informações eram sobre tráfico contra o acusado Vinícius. Explicou que, geralmente, nos casos de tráfico, quem é pego com a droga assume a propriedade para livrar quem não estava perto. A equipe já tinha informações sobre o envolvimento do réu Vinícius e sua companheira Grayce Kelly com o tráfico, mas não havia denúncia sobre o réu Mateus, o qual não conhecia até então. Não se recorda se já realizou buscas naquela casa. Não se recorda se foi encontrado algo na residência, mas acha que apenas foram encontradas drogas na sacola. Não conhece o proprietário daquele imóvel, tampouco sabe se Grayce Kelly e o réu Vinícius locaram a casa. Informou que as denúncias sobre o local ser ponto de tráfico de entorpecentes eram recentes. Não se recorda de ter apreendido drogas em poder de Grayce Kelly e do acusado Vinícius. Informou que uma vez, em abordagem a um usuário, este indicou a residência dos fatos como ponto de venda de drogas. Disse que as drogas foram levadas para o plantão policial na própria sacola em que foram apreendidas, não tendo nenhum lacre. Não se recorda se explanaram ao acusado seus direitos constitucionais.

A testemunha comum Grayce Kelly Regina Daniel, ouvida em juízo (fl. 325), disse ser companheira do acusado Vinícius. Informou que os policiais foram até sua casa afirmando que havia denúncias e que fariam buscas ali. Disse que abriu o portão e os policiais entraram. Informou que o acusado Mateus saiu de lá pulando o muro. Afirmou que um policial foi atrás do acusado Mateus. Disse que o réu Mateus foi detido e levado até sua casa com as drogas. Relatou que autorizou os policiais a fazerem uma busca em sua casa e que nada foi encontrado. Informou que os policiais disseram que “as maconhas” pertenciam ao acusado Mateus. Contou que os policiais queriam que ela fosse para a delegacia como testemunha, entretanto, o réu Vinícius que foi. Informou que não sabe o porquê Vinícius ficou preso. Informou que quando a polícia chegou estava limpando sua casa e não viu se o réu Vinícius abriu o portão para que o réu Mateus entrasse. Disse que sabia que o acusado Vinícius estava em casa e que informou à polícia que ele estava lá. Não viu o acusado Mateus correr da polícia, tendo em vista que estava lá no portão. Não conversou com seu marido Vinícius após a situação. Afirmou que a polícia já foi em sua casa com um mandado, mas que nunca acharam nada. Informou que está presa por tráfico de drogas e que foi presa em sua residência, local dos fatos. Foi presa no dia 15 de novembro. Relatou que foi encontrada cocaína com o acusado Vinícius e foi presa por estar junto com ele. Disse que foi presa anteriormente, em 2019, por tráfico também. Contou que o acusado Vinícius também já foi preso por tráfico, assim como seu pai, na mesma residência. Falou que o acusado Mateus era colega de seu marido Vinícius e que as vezes ia em sua casa. Reafirmou que não viu que horas o acusado Mateus chegou em sua casa no dia dos fatos. Em nenhum momento viu o acusado Mateus em sua residência.

Em seu interrogatório em juízo (fls. 328/329), o réu Mateus Luis Barbosa de Souza disse que no dia dos fatos foi abordado pelos policiais com 40 “balinhas de maconha” e foi levado para dentro da casa de um colega seu, o acusado Vinícius. Informou que não sabe o porquê levaram o réu Vinícius preso junto. Negou que a droga fosse para venda. Negou também que estivesse na casa do réu Vinícius, pois estava no telhado de uma casa ao lado. Disse que saiu correndo porque viu a viatura. Informou que estava no telhado da vizinha porque tinha acabado de sair de uma “biqueira”, entretanto, não sabe o nome da proprietária da casa em alega ter estado. Disse que estava na calçada do lado da casa do réu Vinícius quando viu a

viatura. Informou que estava com "um malote" de entorpecentes e que a sacola encontrada pelos policiais estava em outra casa. Afirmou que estava com 40 porções de maconha. Relatou que correu da polícia e, depois de, aproximadamente, 30 metros, os policiais deram voz de prisão e ele parou. Contou que as 40 porções eram destinadas ao seu uso. Informou que tem problemas financeiros e com o auxílio emergencial comprou essas porções. Disse que gastou R\$ 200,00 com a droga. Afirmou que é usuário de maconha e cocaína. Nega ter visto pinos de cocaína no local dos fatos, apenas na delegacia, assim como os tabletes de maconha. Disse ser amigo do acusado Vinícius e vai em sua casa três vezes na semana. Informou que o acusado Vinícius é usuário de maconha. Não sabia que estavam dizendo que na casa do acusado Vinícius estariam vendendo drogas. Informou que não havia conversado com o acusado Vinícius no dia dos fatos. Negou ter entrado pelo quintal da casa do acusado Vinícius para fugir da polícia. Negou também ter ido à casa do réu Vinícius no dia dos fatos. Nega a propriedade das drogas encontradas na sacola. Afirmou que já foi processado por tráfico de drogas, mas que não foi condenado. Relatou que já foi pego com maconha pela polícia militar. Contou que ia para a casa do acusado Vinícius para conversar. Afirmou ter sido constrangido pelos policiais no dia dos fatos para confessar o tráfico. Contou que as drogas eram para consumo. Informou que durante a abordagem os policiais falaram para ele assumir a propriedade das drogas. Confessou que as drogas em sua posse eram para venda por conta de necessidades que passava. Admitiu que estava na casa do réu Vinícius para beber água. Nega que estava com uma sacola. Informou que a droga estava em sua cintura. Não estava com nenhuma sacola. Reafirmou que as 40 porções eram para venda. Vendia por R\$ 20,00 reais da porção. Informou que comprou as drogas em uma "biqueira" na Rua Antônio Sampaio.

Em seu interrogatório em juízo (fls. 334/335), o réu Vinícius Baldenebro Batista disse que estava em sua casa depois de ter chegado do trabalho. Informou que na residência estavam sua esposa, seu pai, seu sogro e suas enteadas, momento em que o acusado Mateus foi pedir água. Disse que o acusado Mateus estava com uma sacola em suas mãos quando chegou. Informou que estava no fundo de sua casa com o réu Mateus quando os policiais chegaram. Contou que sua esposa foi abrir o portão para os policiais e ele foi para lá também, momento em que os policiais gritaram que tinha alguém pulando o muro da sua casa. Relatou que os policiais saíram correndo atrás do acusado Mateus. Disse que os policiais capturaram o acusado Mateus e o levaram até sua casa com a sacola preta em mãos. Informou que foi questionado pelos policiais sobre as drogas, mas que não sabia nada a respeito. Contou que o acusado Mateus ficou em sua casa por dez minutos. Disse que a sacola que os policiais trouxeram era a mesma sacola que o réu Mateus estava nas mãos quando chegou em sua casa. Negou a propriedade dos entorpecentes para os policiais. Não viu o que tinha dentro da sacola, mas ouviu os policiais falarem que era maconha e pinos de cocaína. Informou que só viu as drogas na delegacia. Negou novamente ter visto as drogas no local dos fatos. Relatou que quando foi até a frente da casa para receber a polícia com sua esposa, um dos policiais viu pelo muro que o acusado Mateus saiu pulando o muro e foi correndo atrás dele. Contou que o muro que o réu Mateus pulou foi o do fundo de sua casa e saiu em outra casa. Negou que tivessem mais pessoas na casa além de sua esposa, suas enteadas e seu sogro. Contou que na hora não entendeu o porquê do acusado Mateus ter fugido, mas que depois imaginou que fosse por causa de drogas. Relatou que conhece o acusado Mateus, mas que nunca ficou sabendo sobre ele usar drogas, apenas que é usuário de maconha. Afirmou ser usuário de maconha também. Afirmou que já foi preso pelo crime de tráfico de drogas, no dia 10 de maio. Relatou que foi preso na mesma rua da casa em que estava no dia dos fatos com pinos de cocaína. Informou que foi preso pela polícia militar (Rocam). Informou que tem problemas com a vizinha por causa de som alto e ela sempre chama a polícia. Disse que a polícia nunca encontrou entorpecentes em sua residência. Acredita que a inimizade causou essa denúncia para a polícia. Informou que faz pouco tempo que foi morar com sua esposa naquela residência; aproximadamente dois meses. Informou ser ajudante de calheiro com seu pai.

Eis a prova oral colhida.

Passo à análise das condutas dos réus de forma individualizada.

Quanto ao acusado Mateus Luís Barbosa de Sousa.

Encerrada a instrução processual, restou demonstrado que o entorpecente apreendido consigo se destinava à comercialização ilícita, diante do que foi declarado pelas testemunhas comuns ouvidas em juízo, bem como pelas circunstâncias fáticas em que a droga foi encontrada, aliado à confissão do acusado, tanto na fase policial quanto judicial.

As testemunhas comuns foram uníssonas ao confirmar que, durante cumprimento de mandado de busca na residência do corréu Vinícius, visualizaram por cima do muro uma movimentação de pessoas no fundo do imóvel. Foi então que o policial Alexandre visualizou o acusado, que vestia camiseta vermelha e detinha uma sacola preta nas mãos, pulando o muro da residência e fugindo pelo telhado das casas vizinhas.

O policial Alexandre conseguiu detê-lo depois de percorridos aproximadamente trinta metros. Quando voltavam à casa de Vinícius, o policial encontrou a sacola preta que estava anteriormente nas mãos de Mateus. Em seu interior foram encontradas grandes quantidades de maconha e cocaína, além de uma balança de precisão.

Ainda, segundo as testemunhas policiais, Mateus assumiu informalmente a posse das drogas, isentando, entretanto, o corréu Vinícius de qualquer envolvimento com o delito.

Diante deste contexto, não há motivos para se desmerecer a palavra dos policiais civis, uma vez que confirmadas pelo auto de exibição e apreensão de fls. 21/22 e pelos laudos periciais realizados às fls. 130/144.

Como é cediço, o testemunho policial é de grande valia na prova do tráfico, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de seu cargo e função, salvo na presença de suspeitas concretas que possam desaboná-lo de confiança no sentido de querer indevidamente prejudicar o réu, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito.

Registre-se que os relatos prestados pelos agentes públicos são coincidentes entre si, estando em sintonia com seus depoimentos colhidos na seara policial (fls. 09/10), o que lhes confere maior densidade probatória, não havendo nenhuma contradição que se preste a abalar, minimamente, a credibilidade das testemunhas. Dessa forma, seus depoimentos devem sim, possuir maior valoração.

Ainda sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, colaciono trecho de acórdão proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça: "É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (AgRg no Ag 1158921/SP; Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, j. 17/05/2011, DJe 01/06/2011).

Caracteriza-se, portanto, a prova testemunhal produzida, como mais um elemento no conhecimento dos fatos pelo julgador, que deve apreciá-la em conjunto com as demais provas existentes nos autos.

Quanto ao acusado, verifica-se que acabou por confessar em juízo que estava vendendo as drogas encontradas pelos policiais, tendo em vista as dificuldades financeiras que estava enfrentando.

Vale destacar que o teor do que foi confessado pelo réu está em consonância com as demais provas colhidas nos autos. A confissão do delito, de forma livre e espontânea, serve como importante elemento de convicção para demonstrar a autoria e amparar a condenação, quando encontrada sustentação nos demais elementos de convicção produzidos, como é o caso dos autos.

De mais a mais, o próprio corréu Vinícius disse que o acusado Mateus, quando chegou em sua casa, estava com uma sacola nas mãos. Informou que estava no fundo do imóvel com Mateus, quando os policiais chegaram. Acompanhou sua esposa até a frente para abrir o portão para os policiais, ocasião em que os agentes avistaram Mateus pulando o muro da sua casa. Viu quando os policiais saíram correndo atrás de Mateus, capturando-o. Depois disso, levaram-no até sua casa, relatando que a sacola que os policiais trouxeram era a mesma sacola que o réu Mateus detinha nas mãos quando chegou em sua casa.

Por sua vez, a testemunha Grayce Kelly Regina Daniel também relatou em juízo que o acusado Mateus saiu de sua casa pulando o muro, mas foi detido pelo policial civil, que o trouxe novamente à casa, juntamente com as porções de droga encontradas com ele.

Ademais, verifica-se que o modo como a droga estava acondicionada e a quantidade apreendida demonstram, de fato, que o entorpecente se destinava ao tráfico. Isto porque foram apreendidas 427,43 gramas de substância entorpecente "Benzoilmetilecgonina", popularmente conhecida como "cocaína", distribuída em 522 microtubos do tipo "eppendorf", além de 830,77 gramas de maconha, divididas em 139 porções, conforme laudos periciais de fls. 23/26 e 130/144.

Cabe ponderar que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse ou guarda do tóxico pelo agente para entrega a terceiro, sendo, portanto, desnecessário que seja o agente flagrado em atos de mercancia ou na posse de apetrechos comumente utilizados para a prática do delito.

Ainda assim, verifica-se que no caso em comento foi encontrada dentro da sacola plástica que estava na posse do acusado uma balança de precisão.

A propósito, sobre o tema este Tribunal já decidiu que: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP63/316, 70/371 e 97/512).

Assim, a conduta do réu, consistente na ação de "trazer consigo" o entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, encontra-se inserida no rol descrito no "caput" do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

De outro lado, analisando os autos, reputo incabível a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em favor do acusado.

Conforme já assentou o C. Superior Tribunal de Justiça, a inserção no ordenamento jurídico da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) teve por escopo diferenciar aquele agente que não é dedicado à prática de ilícitos penais, daquele que efetivamente se dedica ao tráfico de entorpecentes com maior potencialidade lesiva à sociedade, sendo que a aplicação da benesse não pode ocorrer de forma desmedida, mas somente em casos singulares, quando o agente preenche

cumulativamente todos os requisitos, os quais merecem interpretação restritiva, de modo a prestigiar quem efetivamente mereça redução de pena (REsp nº 1.380.741/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016).

Nesse sentido, entendo que o benefício não foi pensado para situações como a retratada nos autos, em que o acusado foi submetido à medida socioeducativa de liberdade assistida, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes durante a adolescência (autos nº 0000648-24.2017.8.26.0603, fl. 66). Além disso, antes mesmo da prática do delito apurado nestes autos, já havia sido condenado por tráfico de drogas nos autos nº 1500269-38.2019.8.26.0603 (fl. 341), embora o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente.

Sendo assim, diante de tal contexto, bem como as demais circunstâncias do delito e elementos de prova existentes nos autos, restou demonstrado que o réu não se trata de traficante eventual, mas sim de pessoa que se dedica habitualmente às atividades ilícitas, o que justifica o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido se posicionou o C. STJ: “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIIS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. (...) Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça.” (EResp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017, g.n.).

E ainda: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA ANTERIOR DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 3. Na hipótese, o pretendido redutor foi afastado com fundamento não só na quantidade e na diversidade do entorpecente apreendido mas também na anterior prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC 588.716/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020, g.n.).

Portanto, em razão de todo o acima exposto, restou demonstrada e caracterizada a conduta do réu pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao acusado Vinícius Baldenebro Batista.

Em consonância com o pedido formulado pelo órgão ministerial, pelo que se pode observar das provas produzidas nos autos, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a prática e participação do acusado no crime de tráfico de drogas.

Segundo relatado pelos policiais civis, solicitaram a expedição de mandado de busca e apreensão para o endereço de residência do réu em virtude de denúncias anteriores no sentido de que ali ocorria a venda de drogas.

Contudo, ao darem cumprimento ao referido mandado, foram atendidos pelo acusado e por sua companheira, os quais negaram a existência de entorpecentes no local. Realizada a revista pessoal e buscas no imóvel, nada de ilícito foi encontrado.

Embora o acusado Mateus tenha fugido com entorpecentes daquela residência, e apesar de existir indícios que foram entregues por Vinícius, não há prova segura vinculando o réu Vinícius à droga apreendida.

Neste contexto, embora haja indícios da prática do tráfico na residência do acusado Vinícius, sobretudo por conta das denúncias anteriores, conforme relatado pelos policiais, bem como em razão dos elementos contidos nos autos - tal como a prisão do réu Mateus depois de ter fugido dos fundos daquele imóvel, a análise acurada do conjunto probatório não permite a prolação de decreto acusatório em desfavor do réu.

Assim, remanescendo dúvida, esta deve favorecer o acusado, à vista do sistema processual penal vigente, fundado na persuasão racional ou livre convicção motivada do julgador, bem como na presunção de inocência, só afastada quando o órgão acusatório se desincumbe do ônus da prova dos fatos descritos e imputados na denúncia.

Portanto, o conjunto probatório, no que tange à autoria, ressoa-se de robustez, mostrando-se insuficiente a comprovação da prática de tráfico por parte do réu Vinícius.

Passo à fixação da pena do réu Mateus Luís Barbosa de Souza.

No que toca às circunstâncias previstas no artigo 42, da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, tenho que o réu, embora primário, ostenta condenação pela prática de tráfico de entorpecentes, praticado anteriormente aos fatos aqui apurados (12/02/2019), mas com trânsito em julgado posterior (11/09/2020), nos autos do processo nº 1500269-38.2019.8.26.0032, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal desta comarca (fl. 341).

Nesse sentido: “A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que condenações por fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior à data do crime em apuração, podem justificar a majoração da pena-base a título de maus antecedentes” (STJ, AgRg no HC 556.142/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020, g.n.)

Por essa razão, fixo a pena acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e multa no valor de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixada no patamar mínimo de 1/30 do salário-mínimo, ante a ausência de elementos que possibilitem aferir a real situação econômico-financeira do acusado.

Incidem no caso as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), vez que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos (fl. 53), bem como da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, por ter o réu confessado o delito em questão. Por esta razão, atenuo

a pena para o patamar mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena a se aplicar.

Inviável, do mesmo modo, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, como delineado na fundamentação supra, razão pela qual torno definitiva a pena acima estabelecida.

Tratando-se de crime equiparado a hediondo (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), considerando-se, ainda, os maus antecedentes do acusado e as circunstâncias judiciais do artigo 42, da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, sobretudo diante da grande quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (427,43 gramas de "cocaína", distribuída em 522 microtubos do tipo "eppendorf", além de 830,77 gramas de maconha, divididas em 139 porções), o réu iniciará o cumprimento de sua pena no regime fechado.

Neste sentido: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ANOTAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. GRANDE QUANTIDADE DROGA. AUMENTO DA PENA-BASE. ART. 42, LEI DE DROGAS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. REGIME FECHADO. ADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 33, § 2º E § 3º, CP). WRIT NÃO CONHECIDO. I - [...] II - O art. 42 da Lei 11.343/2006 prescreve que: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". A quantidade, a natureza e a diversidade de entorpecentes constituem fatores preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes. III - Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior, embora não prevaleça mais para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes. Precedentes. IV - Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. V - O regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06. Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 494525-SP, 2019/0049986-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2019, g.n.)

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena por estarem ausentes os requisitos previstos nos artigos 44, incisos I e III, e 77, "caput", ambos do Código Penal.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, vez que não há nos autos informações mínimas para a análise objetiva da situação carcerária do réu, bem como para a averiguação dos aspectos subjetivos, o que também é requisito para a detração.

DECIDO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do Ministério Público e o faço para:

A) CONDENAR o réu MATEUS LUÍS BARBOSA DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, com regime fechado para o início do cumprimento.

B) ABSOLVER o réu VINÍCIUS BALDENEBRO BATISTA da prática do delito descrito no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

INDEFIRO ao réu MATEUS LUÍS BARBOSA DE SOUZA o direito de recorrer em liberdade pelos mesmos fundamentos explicitados para decretação e manutenção de sua prisão preventiva (fls. 164/165, 232/233 e 281/282), somado à gravidade do crime imputado, bem como para assegurar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, sobretudo agora diante da condenação, em razão do montante e regime de pena imposto.

Recomende-se o réu ao estabelecimento prisional onde se encontra.

Após, com a intimação das partes acerca da presente sentença, expeça-se, com urgência, guia de recolhimento provisória/definitiva.

DECLARO o perdimento da quantia apreendida de R\$ 10,00 (fl. 21) em favor da União, nos termos do artigo 63, da Lei nº 11.343/06, uma vez que inerente ao crime de tráfico praticado.

Por fim, DETERMINO a destruição dos demais objetos apreendidos, por serem produtos ou estarem relacionados à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes praticado pelo sentenciado, expedindo-se o necessário após o trânsito em julgado.

Custas conforme a lei (art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003), observando-se a gratuidade de justiça concedida em favor dos acusados.

P. R. e I.

Araçatuba, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA